

抵押权预告登记后设立的租赁权无权要求“带租拍卖”

——冀某某执行异议案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广西壮族自治区南宁市兴宁区人民法院(2023)桂0102执异63号执行裁定书

2. 案由：执行异议

3. 当事人

申请执行人：某银行广西某分行

被执行人：梁某

异议人(案外人)：冀某某

【基本案情】

2009年1月19日，梁某因购买房产需要向某银行广西某分行贷款47.3万元，为此双方签订《交通银行个人住房抵押贷款合同》，并用其购买的住房为借款提供抵押担保。2009年3月26日，梁某用案涉房屋办理《预购商品房抵押权预告登记》，某银行广西某分行为预告登记权利人。2013年10月11日，

案涉房屋办理房屋他项权证，某银行广西某分行为房屋他项权利人。因梁某未按合同约定按时借款，某银行广西某分行将梁某诉至法院。广西壮族自治区南宁市兴宁区人民法院(以下简称兴宁法院)作出(2015)兴民二初字第1267号民事判决书，判决梁某承担还款责任，某银行广西某分行对处分抵押房产所得价款享有优先受偿权。因梁某未履行生效判决所确定的义务，某银行广西某分行向兴宁法院申请强制执行。

在执行过程中，兴宁法院作出民事裁定拍卖梁某名下的南宁市西乡塘区心圩江东路10号盛天熙园的房产。冀某某以房产承租人身份提出执行异议，要求法院在房产拍卖过程中带租拍卖。

根据冀某某提交的证据载明：2011年3月4日，梁某与冀某某签订《房屋租赁合同》，约定梁某将房产出租给冀某某，租赁期限17年，自2011年3月4日至2028年3月4日，总租金17万元、押金3万元，签合同当日支付租金17万元、押金3万元等。2011年3月4日，冀某某向梁某银行账户转账20万元。2011年12月25日，梁某与冀某某签订《房屋租赁合同》，约定梁某将案涉房产出租给冀某某，租赁期限18年，自2028年3月5日至2046年3月5日，总租金18万元、押金8800元，签合同当日支付租金18万元、押金8800元等。2011年12月25日，冀某某向梁某银行账户转账188800元。

同时查明，经检索广西法院办案系统，冀某某与梁某因借款合同纠纷等案件在南宁市西乡塘区人民法院诉讼、执行。

【案件焦点】

抵押权预告登记后设立的租赁权是否可以排除执行。

【法院裁判要旨】

广西壮族自治区南宁市兴宁区人民法院经审理认为：首先，《中华人民共和国民法典》第二百二十一条第一款规定：“当事人签订买卖房屋的协议或者签订其他不动产物权的协议，为保障将来实现物权，按照约定可以向登记机构申请预告登记。预告登记后，未经预告登记的权利人同意，处分该不动产的，

不发生物权效力。”梁某因购买案涉房屋需要向某银行广西某分行申请贷款，并用其购买的房屋为借款办理抵押担保，为此办理《预购商品房抵押权预告登记》，某银行广西某分行为预告登记权利人，其享有的是当抵押登记条件成就或约定期限届满对梁某抵押房屋办理抵押权登记的请求权，并可排除性地对抗他人针对梁某抵押房屋的处分。梁某作为借款人，用案涉房产为借款提供抵押担保的意思表示是明确的，只是当时案涉房屋尚不具备不动产登记手续未能转化为正式的抵押登记，梁某为借款而向某银行广西某分行的抵押行为设立在前。

其次，根据《中华人民共和国民法典》第七百零五条规定，租赁期限不得超过20年。2009年1月19日，梁某用案涉房屋为借款向某银行广西某分行提供抵押担保后，于2011年3月4日与冀某某签订《房屋租赁合同》，租赁期限17年，自2011年3月4日至2028年3月4日。2011年12月25日，梁某与冀某某再次签订《房屋租赁合同》，租赁期限18年，自2028年3月5日至2046年3月5日。双方两次签订的租赁合同租赁期限达到35年，明显超过法律规定的最长期限，且两次租金均是一次性支付。结合梁某与冀某某之间涉及借款等事实，双方的租赁行为不符合常理，缺乏合理性。

最后，梁某未按抵押贷款合同的约定按时偿还贷款，某银行广西某分行将其诉至法院，判决生效后梁某等未履行生效判决所确定的义务，直至案件进行执行程序仍未清偿完案涉债务。为此某银行广西某分行行使抵押权处置案涉房屋，冀某某主张的长期租赁关系，阻碍了房产的处置及交付，可能影响不动产在拍卖、变卖过程中的可转换的价值，从而可能直接影响抵押权人可以通过执行程序实现的抵押权，清偿债务的可能性降低。若案涉房屋负担该租赁关系进行评估、拍卖，势必将会影响某银行广西某分行抵押权的实现，为此会严重贬损抵押权人的利益。综上，冀某某要求带租拍卖的请求不能成立，应不予支持。

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第四百六十三条第一款第一项，《最高人民法院关于人民法院民事执行中拍卖、变卖财产的规定》第二十

八条第二款的规定，裁定如下：

驳回异议人冀某某的异议请求。

【法官后语】

在不动产强制执行过程中，抵押权人在实现抵押权时常常会涉及抵押不动产的拍卖处置，不动产存在的抵押权和租赁权的冲突也十分常见。租赁人依据“买卖不破租赁”“抵押不破租赁”来主张其自身权利，要求在拍卖中“带租拍卖”或者停止拍卖，意图阻止法院的拍卖交付行为，但也存在被执行人与租赁人恶意串通、虚构租赁关系来阻止法院执行。不动产拍卖处理结果涉及抵押权人、承租人、被执行人等多方利益，因租赁权的设立较为隐秘，其识别较为困难。

一、不动产强制执行中抵押权与租赁权冲突的处理原则

《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）第四百零五条规定：“抵押权设立前，抵押财产已经出租并转移占有的，原租赁关系不受该抵押权的影响。”《最高人民法院关于人民法院民事执行中拍卖、变卖财产的规定》第二十八条第二款规定：“拍卖财产上原有的租赁权及其他用益物权，不因拍卖而消灭，但该权利继续存在于拍卖财产上，对在先的担保物权或者其他优先受偿权的实现有影响的，人民法院应当依法将其除去后进行拍卖。”上述法律规范明确了在抵押权与租赁权发生冲突的情况下，以权利设立时间作为判断依据，以保护设立在先权利作为处理原则。在涉及不动产强制执行中，具体为：一是抵押权设立时间晚于租赁权。在拍卖中租赁关系仍然存在，这便是“买卖不破租赁”“抵押不破租赁”。执行法院认定“带租拍卖”后，在拍卖成交后执行法院不能要求承租人对租赁物转移占用使用。买受人对拍卖财产的使用要受限于租赁期限的约定。二是抵押权设立时间早于租赁权。在拍卖中不带租拍卖，租赁权不能对抗抵押权。若租赁权影响了抵押权的实现，法院应当依法将其除去后进行拍卖。

二、抵押权预告登记效力对抗租赁权的类推适用

前述讨论的抵押权是已经经过正式登记设立的情形下，其与租赁权发生冲

突可以直接适用相应的法律规范进行判断处理。而与在抵押权预告登记之后本登记之前形成的租赁权发生冲突如何处理，并无法律直接规定。

《民法典》第二百二十一条第一款规定：“当事人签订买卖房屋的协议或者签订其他不动产物权的协议，为保障将来实现物权，按照约定可以向登记机构申请预告登记。预告登记后，未经预告登记的权利人同意，处分该不动产的，不发生物权效力。”以及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉物权编的解释（一）》第四条规定：“未经预告登记的权利人同意，转让不动产所有权等物权，或者设立建设用地使用权、居住权、地役权、抵押权等其他物权的，应当依照民法典第二百二十一条第一款的规定，认定其不发生物权效力。”预告登记不能发生物权变动效果，但可以对权利人对不动产的处分权进行限制。抵押权预告登记是正式登记无法办理时，当事人保障其将来所取得的抵押权而办理的临时登记，在于具备办理抵押登记时预告登记权利人具有排他效力的请求权。预购商品房抵押办理主要步骤为：抵押权预告登记—建筑物竣工验收交付办理首次登记—购房人办理所有权登记—银行办理抵押权正式登记。在此期间存在一些不确定风险因素，特别是租赁权的设立比较随意和隐秘，给执行财产处置工作带来极大的障碍。

具体到本案，2009年3月26日，梁某用案涉房屋办理《预购商品房抵押权预告登记》，某银行广西某分行为预告登记权利人。2013年10月11日，案涉房屋办理房屋他项权证，某银行广西某分行为房屋他项权利人。而根据冀某某提供的证据，其与梁某于2011年3月4日签订租赁合同。从时间点上看来抵押权正式登记时间晚于租赁权的设立时间，如果将正式登记时间点作为判断标准，好像可以构成“带租拍卖”，但对于一个已经设立长期租赁具有居住性质的不动产，势必会影响拍卖成交及抵押权的实现，这对于经过预告登记的抵押权人来说违背公平原则。

抵押权溯及力及顺位效力的合法原则。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉有关担保制度的解释》第五十二条第一款规定：“当事人办理抵押预告登记后，预告登记权利人请求就抵押财产优先受偿，经审查存在尚

未办理建筑物所有权首次登记、预告登记的财产与办理建筑物所有权首次登记时的财产不一致、抵押预告登记已经失效等情形，导致不具备办理抵押登记条件的，人民法院不予支持；经审查已经办理建筑物所有权首次登记，且不存在预告登记失效等情形的，人民法院应予支持，并应当认定抵押权自预告登记之日起设立。”在正常情形下，办理抵押权登记需要进行相应的权属转换登记。特别是抵押的建筑物尚未建成的，办理抵押权预告登记后，应在具备抵押登记条件之日起九十日内办理抵押登记，否则预告登记失效。为避免当事人诉累，上述司法解释规定在诉讼中对具备抵押登记条件时，且预告登记仍在有效期内，可以认定抵押权的成立，此时抵押权的设立时间为预告登记之日，将抵押权本登记的效力溯及至预告登记之日，保证其顺位效力，自然预告登记之日之后对不动产的处分行为不具有对抗性。据此，在抵押权预告登记之后本登记之前形成的租赁权与抵押权发生冲突的，前述条款的适用可以类推到本案的处理具有合法性，应该赋予抵押权更高的对抗效力。本案中，首先，梁某向某银行广西某分行借款并用房产提供抵押担保，某银行广西某分行为预告登记权利人，条件成就后某银行广西某分行办理正式抵押登记手续。梁某抵押登记行为发生在前，某银行广西某分行属于善意相对人，其合法利益应该得到保护，应该对其抵押权赋予其顺位效力。其次，从租赁权设立情况来看也存疑，在前述期间内梁某又与冀某某在极短时间内签订两次租赁合同，其租赁期限合计长达35年，明显超过法律规定最长20年的期限，租金也是一次性支付，结合二人已经涉及其他纠纷的事实，不排除双方恶意串通损害本案执行的情形，双方的租赁行为不符合常理，缺乏合理性。法院并未认定案涉不动产“带租拍卖”，裁定作出后，各方均未提起诉讼。

编写人：广西壮族自治区南宁市兴宁区人民法院 王星

